

1502530-29.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/05/2022

... pela desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas; ou ainda em caso de condenação por delito de tráfico, fixação da pena em seu piso mínimo, alegando que os antecedentes do acusado são antigos e portanto, não podem ser considerados, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do réu, e ainda a aplicação da benesse prevista ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1502530-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502530-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EWERTON CALADO DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

JACKY LEMMON CARLOS BENGUELA e FENEK PINHEIRO SANTO, qualificados nos autos foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 e EWERTON CALADO DA SILVA também qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal e 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta do incluso inquérito policial no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 20 horas, na Rua Hiperion, na altura do nº 10, São Mateus, nesta Capital, EWERTON CALADO DA SILVA, JACKY LEMMON CARLOS BENGUELA e FENEK PINHEIRO SANTOS, agindo em concurso e com identidade de propósitos, traziam consigo e transportavam, para fim de tráfico, 196 (cento e noventa e seis) eppendorfs contendo "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É dos autos, ainda, em data não apurada com precisão, no período de 07 de dezembro de 2021 a 29 de janeiro de 2022, EWERTON CALADO DA SILVA, qualificado nos autos (fl. 20), adquiriu, em proveito próprio, o veículo Chevrolet Chevette SL, placas CJX-3189, que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida, o réu Fenek foi citado e notificado a fls. 204 enquanto Jacky foi citado e notificado em audiência, ocasião em que ambos apresentaram defesa prévia. Após a manutenção do recebimento da denúncia, foram ouvidos a vítima do crime de furto proprietário do veículo Chevrolet Chevette, placas CJX 3189, dois policiais e os réus foram interrogados. (fls. 207/208 e 232/233). Encerrada no mais a instrução criminal quanto aos corréu Jacky Lemmon e Fenek, as partes foram instadas a apresentar seus memoriais.

O Ministério Público se manifestou a fls. 245/252, ocasião em que requereu no que toca ao corréu Ewerton a aplicação do disposto no art. 366 do Código de Processo Penal. Já quanto aos corréus presos buscou a condenação de ambos como incurso no art. 33 da lei 11.343/06.

A Defesa dos acusados, por sua vez, pugnou em sede preliminar a nulidade do feito pelos seguintes motivos: a ilegalidade da busca pessoal, que teria sido feita em dissonância com o previsto no CPP; o reconhecimento da prova ilícita em razão da não realização do "aviso de Miranda" quando da prática da prisão em flagrante" e consequente absolvição nos termos do art. 386, III do CPP. No mérito, propriamente dito, requereu ainda pela improcedência da ação penal por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Em caso de eventual condenação, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas; ou ainda em caso de condenação por delito de tráfico, fixação da pena em seu piso mínimo, alegando que os antecedentes do acusado são antigos e portanto, não podem ser considerados, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do réu, e ainda a aplicação da benesse prevista no §4º, do art.33 da referida lei, com fixação de regime aberto ou no máximo semiaberto para início de cumprimento de pena e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No que toca ao réu Fenek, sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Por primeiro, não há que se falar em falta de comunicação ao réu de seu direito de ficar em silêncio.

Isso porque, não há nos autos provas dessa alegação por parte do acusado, em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido.

Ademais, verifica-se que as alegações prestadas pelos policiais civis apenas o réu Fenek confessou ser o proprietário das drogas, fatos estes que também foram confidenciais à autoridade policial consoante o termo de interrogatório de fls. 08, após ser lhe avisado, nos seguintes termos: "Cientificado(a) da imputação que lhe é feita e das provas contra si existentes, ao ser interrogado(a) pela Autoridade Policial, às perguntas respondeu: cientificado sobre seus direitos constitucionais, disse que não possui advogado para acompanhar os trabalhos de Polícia Judiciária; sobre os fatos disse que não tinha ciência do carro e que as drogas eram suas para o seu consumo pessoal. Questionado, o interrogado negou que tenha sintomas do COVID 19. Disse que não deseja informar ninguém de sua prisão. Relata que possui três filhos: Leonardo de 4 anos de idade, que fica aos cuidados da sua genitora Janaína; Gustavo de 11 anos de idade que fica aos cuidados de sua genitora Jakeline e Angélica de 7 anos de idade que fica aos cuidados de sua genitora Amanda. Por fim, o interrogado foi questionado sobre ter sofrido algum tipo de agressão física ou constrangimento por parte dos policiais militares ou civis, respondeu que não".

No mesmo sentido também o corréu Jacky Lemmon Carlos Benguela consoante seu interrogatório de fls. 06: "Cientificado(a) da imputação que lhe é feita e das provas contra si existentes, ao ser interrogado(a) pela Autoridade Policial, às perguntas respondeu: cientificado sobre seus direitos constitucionais, disse que não possui advogado para acompanhar os trabalhos de Polícia Judiciária; sobre os fatos disse que não tem nada a ver com o carro, que estava indo embora para casa, que não conhece Ewerton direito, que o conheceu esses dias fumando maconha, sobre as drogas disse que não sabia delas. Questionado, o interrogado negou que tenha sintomas do COVID 19. Disse que não deseja informar ninguém de sua prisão. Relata que não tem filhos. Por fim, o interrogado foi questionado sobre ter sofrido algum tipo de agressão física ou constrangimento por parte dos policiais militares ou civis, respondeu que não.

Ora, o que seria então o "aviso de Miranda" senão os esclarecimentos prestados pela autoridade policial ao réu?

Por outro lado, apenas para que não seja alegada omissão quanto a tal direito por

parte dos policiais militares, repita-se que a abordagem foi oral, cabendo a parte alegar e comprovar o fato que pretende ser utilizado para anular a prova, o que sequer foi mencionado pelos dois réus nas duas oportunidades em que foram ouvidos. Também não há que se falar busca pessoal ilícita, já que segundo os depoimentos dos autos, o veículo em que os três réus estavam somente foi abordado porque todos estavam nos bancos da frente, situação essa estranha e bastante suspeita.

Mais uma vez, o que seria a fundada suspeita, que autoriza a busca pessoal, e está prevista no parágrafo único, do art. 240, do CPP, senão três pessoas amontoadas todas elas no banco da frente do um veículo?

Superadas todas as preliminares levantadas pela Defesa, verifica-se que a materialidade do delito restou cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e laudo de constatação dos entorpecentes, pelo laudo pericial com resultado positivo para cocaína, (fls. 162/164), bem como pela prova oral colhida em solo policial e em juízo.

Quanto a autoria considerando as versões apresentadas nos autos não há dúvidas quanto a ela com relação ao réu FENEK PINHEIRO SANTOS.

Com efeito, o réu nas duas oportunidades em que foi ouvido não negou ter sido preso na posse das drogas apreendidas.

Tais fatos foram devidamente confirmados pelos depoimentos dos dois policiais que fizeram a apreensão dos réus.

Ambos relataram, tanto em sede policial como em juízo que estavam em patrulhamento de rotina e visualizaram um veículo GM Chevette em atitude suspeita e resolveram aborda-lo. Em revista pessoal com os réus nada de ilícito foi encontrado, no entanto, em cima do banco do passageiro havia um sacola dentro da qual foram encontradas mais de 100 porções de cocaína e que de pronto o réu Fenek disse que as drogas lhe pertenciam e os outros dois réus afirmaram que não tinham conhecimento de que dentro do veículo havia entorpecentes.

É fato que o réu Fenek, ao ser interrogado afirmou que tais entorpecentes eram para seu uso próprio e que os outros dois acusados não sabiam que ele trazia consigo tais drogas.

Sua versão contudo, longe de ser a confissão de que a droga era apenas para seu consumo próprio, como quis fazer crer o combativo Defensor, também não veio corroborada por outras provas, sobretudo em razão da grande quantidade de drogas.

Veja-se que a quantidade de droga apreendida em poder do acusado, e as circunstâncias da prisão, já são suficientes para caracterizar o crime previsto no "caput" do art. 33 a Lei de Drogas, ainda mais porque o réu não soube esclarecer o porquê trazia tamanha quantidade de drogas durante a noite, apenas afirmando que as comprara para consumo.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

"PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Neste ponto afasta-se por completo o requerimento de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art.28 do diploma legal citado.

Cabe ainda, aqui destacar que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais e agentes públicos aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial ou guarda municipal

somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos, indício que qualquer tipo de perseguição pelo policiais contra o acusado o acusado, ao contrário tanto o réu como os dois policiais ouvidos apresentaram sempre a mesma versão de que Fenek confessou que era o único proprietário das drogas encontradas no veículo, fato este que confirma que a posição desta magistrada e acima citada é a que deve ser adotada, sem quaisquer reservas.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Assim com relação ao corrêu Fenek, caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

O réu é tecnicamente primário, no entanto consoante certidões de fls. 74/75, já foi condenado definitivamente pelo crime de roubo, cuja pena privativa de liberdade foi extinta em 2014, conforme folhas de antecedentes criminais 53/58, fato este que demonstra sua personalidade voltada para o crime e que sim tem o condão de aumentar a pena base, já que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Neste ponto, salienta-se que não há que se falar em desconsideração das condenações acima apontadas apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Veja-se que a expressão "muito antiga", utilizada para requerer o afastamento das condenações por parte da combativa Defesa, é imprecisa e pode por vezes levar a situações de injustiça e até de quebra do princípio da individualização da pena, devendo o critério do julgador ser objetivo e fundado em fatos concretos, como os aqui apontados.

Assim sendo, a pena base deve ser aumentada em 1/6 chegando-se a 05 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, deve-se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que ainda assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Ainda mais na época dos fatos em que as restrições foram abrandadas e o que se viu foi a chegada de uma nova variante a Ômicron e novo aumento de casos da doença e de centenas de morte.

Neste ponto respeitadas as posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20.

Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020- "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda. Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP -Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 -Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020).

Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

9ª Câmara Criminal- Des. Fátima Gomes: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.

Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se.

Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la.

Portanto, a pena deve ainda ser aumentada em mais 1/6, totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Por outro lado, não há atenuantes a se considerar, já que não houve no caso em tela, confissão do crime por parte do corréu FENEK, que disse apenas que as drogas eram suas mas que seriam para seu consumo próprio.

Na terceira fase da dosimetria da pena, se mostra incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão dos maus antecedentes atestados nos autos, há provas de que o réu faz da atividade criminosa uma prática, e ainda em razão da grande quantidade de cocaína que era transportada pelo réu, já que não é crível que alguém desconhecido do mundo do tráfico seja aliado a transportar tamanha quantidade de drogas, notadamente pelo alto valor de comércio. Ausentes outras causas modificadoras torno definitiva a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, fixados no mínimo legal, já que não há nos autos provas da condição econômica do acusado.

Já no toca ao corréu JACKY LEMMON CARLOS BENGUELA respeitado o posicionamento do combativo Promotor de Justiça que atua perante este juízo, em face dos depoimentos colhidos nos autos, outra solução não há senão a absolvição do réu. Isso porque, o que temos de concreto, não nos permite afirmar com certeza de que o réu também trazia drogas para o fim de comércio de terceiros.

Os dois policiais nas oportunidades em que foram ouvidos disseram que os três réus estavam sentados nos bancos dianteiros do veículo, que as drogas foram encontradas em uma sacola em cima do banco e que de pronto o corréu Fenek confessou a posse dos entorpecentes.

Eles afirmaram, ainda que os outros réus disseram que não tinham ciência de que o réu Fenek trazia as drogas.

Fenek por sua vez, também confessou ser o único proprietário das drogas e confirmou que ele e Jacky estavam de carona no carro de Ewerton e que os dois não sabiam que ele trazia consigo a sacola com as drogas.

Os três réus ainda confirmaram essa versão quando interrogados perante a autoridade policial e em juízo o réu Jacky ficou em silêncio, atitude esta que não pode em hipótese alguma interpretada em seu desfavor, sob pena de se ferir um direito que lhe é assegurado por lei.

Desse modo, não é dado ao magistrado presumir a autoria do crime imputado ao réu na denúncia.

Firme é a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Deve-se deixar claro, ainda, que as declarações prestadas na fase administrativa, foram suficientes apenas para embasar a propositura da ação penal mas não foram suficientes para embasar a condenação do réu. Desse modo, face ao princípio "in dubio pro réu", como o conjunto da prova não autoriza afirmar a autoria do crime, a solução absolutória é que se impõe.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu FENEK PINHEIRO SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 33,

"caput", da Lei nº 11.343/06, a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, fixados no mínimo legal, e para ABSOLVER o réu JACKY LEMMON CARLOS BENGUELA, das imputações que lhe foram feitas na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razão da quantidade de pena aplicada ao réu Fenek, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Por fim, considerando os maus antecedentes atestados nos autos e ainda o disposto no art. 2º da Lei de Crimes Hediondos, o regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado, pois se ajusta e convém ao acusado pela manifesta periculosidade e insolente menoscabo das regras que disciplinam o convívio social, já que solto, novamente foi preso pela prática de novo crime.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontram, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que os condenou. Portanto, não poderá apelar desta em liberdade.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar dos acusados que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Condeno o réu FENEK PINHEIRO SANTOS ao pagamento das custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, já que por ora não ha nos autos provas de sua hipossuficiência.

Diante da absolvição do réu JACKY LEMMON CARLOS BENGUELA, há que se falar em custas diante da natureza da decisão.

Por fim, considerando que foi isentado de pena, diante de sua absolvição, expeça-se com relação ao corréu JACKY LEMMON CARLOS BENGUELA, alvará de soltura, clausulado, com urgência.

Com relação ao corréu EWERTON CALADO DA SILVA, verificado que não foi localizado nos endereços constantes dos autos para ser pessoalmente citado e que deixou o acusado de comparecer em juízo para formalizar sua citação pessoal, bem como não constituiu defensor para oferecer resposta escrita e ainda considerando a manifestação do Ministério Público manifestou-se à fls. 246, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, suspendo o curso do processo e do lapso prescricional.

A cada doze meses, juntem-se informações carcerárias e folha de antecedentes atualizadas.

Em havendo recurso por parte do réu Fenek, desmebrem-se os autos com relação a ele para o devido processamento do recurso.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de execução definitiva e oficiem-se TRE e IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada aos autos, abra-se vista às partes para ciência e eventual manifestação.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA